

1500520-55.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Lizandra Maria Lapenna Peçanha

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... de maconha e 'crack' para realizar tráfico de drogas. No dia dos fatos, policiais militares se dirigiram ao endereço acima mencionado - já conhecido ponto de tráfico de drogas - e realizaram a incursão em uma viela, sendo que uma equipe partiu de cima para baixo e outra na direção oposta. Em dado momento, os policiais avistaram cinco indivíduos, sendo que três deles, os ora ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

4ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, . - Vila Tereza

CEP: 09606-000 - São Bernardo do Campo - SP

Telefone: (11) 4330-1011 - E-mail: saobernardo4cr@tjsp.jus.br

1500520-55.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500520-55.2022.8.26.0537

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Indiciado:

LUCAS OLIVEIRA DE AZEVEDO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lizandra Maria Lapenna Peçanha

2022/000317

VISTOS.

LUCAS OLIVEIRA DE AZEVEDO, JEAN PIERRY DOS SANTOS GOMES e EDUARDO ALVES SILVA, qualificado nos autos, foram denunciados como incursos nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 11 de março de 2022, por volta das 17h40, na Rua Ana Julia Luiz, 1, bairro Ferrazópolis, nesta cidade e Comarca, previamente ajustados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si, traziam consigo e tinham em depósito, para fins de venda, drogas, sendo 79 invólucros plásticos contendo 172,99 gramas de maconha, 148 invólucros plásticos contendo 67,52 gramas de cocaína e 35 invólucros plásticos contendo 20,26 gramas de 'crack', sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de págs. 21/22 e laudo de constatação de págs. 40/42.

Segundo narra a denúncia, nas condições acima mencionadas os réus traziam consigo diversas porções de maconha e 'crack' para realizar tráfico de drogas. No dia dos fatos, policiais militares se dirigiram ao endereço acima mencionado - já conhecido ponto de tráfico de drogas - e realizaram a incursão em uma viela, sendo que uma equipe partiu de cima para baixo e outra na direção oposta. Em dado momento, os policiais avistaram cinco indivíduos, sendo que três deles, os ora réus, correram para dentro de um barraco sem porta, aparentemente abandonado, ao passo que os

outros dois eram moradores e nada de ilícito foi encontrado com eles. Prosseguindo na abordagem, os policiais localizaram com Eduardo uma folha com anotações da contabilidade do tráfico e ao lado do barraco onde os réus estavam foi encontrada uma bolsa preta com dezenas de porções individuais de maconha, cocaína e 'crack'. Nesse contexto, os réus foram detidos em flagrante e conduzidos à delegacia de polícia.

Os réus Jeans e Eduardo foram devidamente notificados em 25 de abril de 2022 (págs. 491 e 493), sendo que todos eles apresentaram defesa preliminar por intermédio de advogados constituídos (Lucas - págs. 369/392 / Eduardo - págs. 397/418 e Jean - págs. 330/350). Apesar de suas defesas preliminares, a denúncia foi recebida em 27 de abril de 2022 (pág. 434).

A seguir, eles foram devidamente citados em 8 de junho de 2022 (pág. 497 - Jean Pierry), 14 de junho de 2022 (pág. 499 - Lucas) e em 28 de junho de 2022 (pág. 504 - Eduardo).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e três testemunhas de defesa, com interrogatório dos réus ao final.

A instrução foi encerrada, tendo as partes se manifestado em alegações finais, ocasião em que o Ministério Público pediu a procedência parcial da ação penal, com a condenação dos réus Jean Pierry e Eduardo nos exatos termos da denúncia e a absolvição do réu Lucas. De outra feita, a defesa dos réus Lucas e Eduardo pediu, em preliminar, o reconhecimento da ilicitude da prova feita em relação ao telefone celular apreendido e no mérito, a absolvição deles pela fragilidade do conjunto probatório ou, em caso de condenação, o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º da lei de Entorpecente, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e direito de recorrerem em liberdade. Por fim, a defesa do réu Jean Pierry também pediu, em preliminar, o reconhecimento da ilicitude da prova feita em relação ao telefone celular apreendido e no mérito, a sua absolvição diante da falta de provas ou a desclassificação para o crime de uso de entorpecente ou, em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo, reconhecimento da atenuante da menoridade, além da substituição da pena.

O laudo de exame químico toxicológico foi juntado às págs. 459/461.

É o RELATÓRIO.

Passo a FUNDAMENTAR e DECIDIR.

Primeiro, passo a analisar a preliminar arguida pelas defesas de Eduardo e Jean Pierry.

Não é caso de reconhecer a ilicitude da prova colhida através de um vídeo feito com o telefone celular de Jean, uma vez que conforme afirmado pelos policiais, Jean foi quem entregou o telefone aos policiais assim que solicitado.

A alegação de que ele foi coagido a entregar tal aparelho não veio amparada por nenhum elemento de prova, apesar da juntada do documento de pág. 360.

Isso porque, os fatos ocorreram em 11 de março de 2022, sendo que tal carta somente foi escrita em 06 de abril de 2022, após quase um mês do ocorrido e, sobretudo, após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.

Importante consignar que Jean, ao ser interrogado na delegacia de polícia, não só confirmou que o telefone celular era de sua propriedade, como autorizou a autoridade policial a extrair o vídeo para anexar ao inquérito policial (pág. 11). E quando passou por audiência de custódia, ele nada mencionou sobre ter sido coagido pela polícia militar ou civil, já que não há nenhuma menção na decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, determinando a apuração de eventual abuso por parte da polícia militar ou civil (págs. 130/133).

No mais, tal alegação de ambas as defesas já havia sido analisada e afastada por essa magistrada em decisão, que sequer sofreu impugnação, conforme se verifica nas págs. 433/435, razão pela qual ela fica mantida.

No mérito, apesar de as defesas pedirem absolvição deles, as provas colhidas no curso da instrução processual são suficientes para embasar o decreto condenatório, ao menos em parte.

Interrogado em Juízo, Lucas negou a prática do delito, afirmando que, no dia dos

fatos, encontrou com Eduardo e que foram para dentro do barraco usar droga, quando a polícia entrou no local e os abordou. Disse que Jean também estava no local, usando entorpecente.

O réu Jean, quando interrogado, também negou a acusação, narrando que também estava no local usando droga junto com Eduardo e Lucas e que Eduardo havia dito a ele que tinha alugado aquele barraco. Com relação ao telefone celular, disse que foi coagido pela polícia a entregá-lo.

Por fim, Eduardo também negou a acusação e declarou que estava no barraco usando droga com Jean e Lucas. Ainda, negou que estivesse com alguma anotação e que teria tentado trocar de roupa.

A testemunha Elias do Amaral Cruz, policial militar, relatou que estava designado para a operação "GRANDE ABC MAIS SEGURO", quando rumou para o local dos fatos, um conhecido ponto de mercancia de drogas. No local, avistou cinco pessoas, sendo que duas delas eram moradores e as outras três, ao verem a polícia, entraram no barraco. Todavia, elas foram abordadas, sendo que com Eduardo foram localizadas anotações relativas ao tráfico de drogas. Afirmou que Jean estava mexendo no telefone celular, tentando apagar um vídeo. Ele foi indagado a respeito e acabou entregando o telefone para a polícia, sendo que o vídeo mostrava Eduardo mexendo em uma bolsa com drogas. Disse que Jean filmava Eduardo realizando o tráfico de drogas e coletando dinheiro. Acrescentou que Eduardo, ao entrar no barraco, mudou de roupa. Todavia, disse que a roupa que ele estava anteriormente, foi localizada dentro do barraco. A bolsa com as drogas estava do lado de fora do barraco. Com relação ao réu Lucas, alegou que ele estava junto com os outros dois acusados, mas que não estava com nada de ilícito. Por fim, acrescentou que eles, informalmente, confessaram que vendiam drogas, sendo que dois deles ficavam observando para avisar a chegada da polícia.

O outro policial ouvido confirmou a declaração de seu colega, relatando que foram até o local, já conhecido como ponto de venda de drogas, ocasião em que avistaram cinco indivíduos, sendo que dois deles ficaram do lado de fora do barraco e os outros três entraram dentro dele. Os dois primeiros eram moradores do local, sendo que os réus, que estavam dentro do barraco, foram abordados, sendo que com Eduardo localizaram algumas anotações e com Jean foi localizado um telefone celular, onde havia um vídeo mostrando Eduardo com uma bolsa e contando dinheiro. Disse que a bolsa foi localizada por outra equipe, próxima ao barraco e que nada foi localizado com Lucas. Acrescentou que eles confessaram informalmente que um vendia droga, enquanto os outros dois ficavam de campana.

A testemunha de defesa de Ayone, amiga da esposa de Jean, apenas disse que ele estava dentro da casa de um amigo, quando foi abordado.

Marcelo e Rafael afirmaram apenas que trabalharam junto com Jean, mas que nada sabiam em relação aos fatos.

Assim, do exposto, verifica-se que a autoria delitiva para os réus Jean Pierry e Eduardo surge dos autos de forma clara e evidente, uma vez que os policiais foram firmes quando afirmaram que encontraram anotações relativas à venda de entorpecentes com Eduardo e um vídeo filmado por Jean, mostrando Eduardo com a sacola de drogas e contando dinheiro.

E nesse contexto, há que se ressaltar que os policiais não teriam motivo nenhum para incriminar os acusados, posto não haver nos autos qualquer elemento concreto capaz de evidenciar a intenção deles de incriminar falsamente Jean e Eduardo, uma vez que sequer os conheciam.

Como se não bastasse, não se olvide de que, na condição de servidores públicos e no exercício de suas funções, eles gozam de presunção relativa de que atuam conforme a lei, somente ilidida por inequívoca prova em contrário.

Além disso, o Código de Processo Penal nada diz a respeito do valor de seus testemunhos. Portanto, eles terão o mesmo valor de qualquer outro depoimento prestado em juízo.

Também, há que se considerar que eles prestam o depoimento sob compromisso de dizer a verdade como qualquer outra pessoa, não havendo razões para, a princípio e sem motivo concreto e relevante, desconfiar de suas declarações.

Nesse sentido, os tribunais já se manifestaram:

STJ: "Processual Penal. Narcotráfico. Flagrante. Prova Policial. Validade. Reiterada jurisprudência sobre a eficácia probatória dos testemunhos reiterados em juízo pelos policiais que flagraram a prática do crime" (RSTJ 110/384). TJS: "Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido" (JTJ 208/273). TJSP: "Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição". (RT 614/275). TJMG: "Os policiais não são proibidos de prestar depoimento nos processos de cuja fase policial tenham participado, seja efetuando a prisão do agente, seja apreendendo o objeto do crime. De outro lado, a declaração de inidoneidade é específica e não genérica, não podendo abranger toda uma categoria de pessoas, devendo ser alegada e demonstrada em cada caso." (RT 604/407).

Como se não bastasse, os réus foram presos em flagrante delito, na posse dos entorpecentes e do dinheiro, o que traz a certeza visual do crime.

E, segundo os policiais, Eduardo estava na posse de anotações relativas à contabilidade do tráfico de drogas, sendo que tal documento foi devidamente apreendido e periciado (págs.315/321).

Por outro lado, as versões dadas por Jean Pierry e Eduardo em juízo não encontraram o menor amparo nas provas produzidas, até mesmo porque os policiais foram firmes quando afirmaram que eles foram abordados e, ao verem um vídeo por eles mostrado, constataram que Eduardo estava mexendo em uma bolsa preta, que foi localizada por equipe contendo drogas, contendo dinheiro.

Outrossim, a despeito de Jean ter afirmado em juízo, que foi coagido a entregar seu telefone à Polícia Militar; quando ouvido perante a autoridade policial, não só permitiu a extração do vídeo de seu aparelho, mas também confirmou ter gravado o vídeo, em que Eduardo aparecia mexendo na bolsa com drogas (pág. 11).

E Eduardo, quando interrogado na delegacia de polícia, embora tenha negado a prática delitativa, confirmou que foi filmado mexendo na bolsa preta e ainda acrescentou que ela era a mesma que ele havia utilizado no dia anterior para vender entorpecente (pág. 12).

Ainda, cumpre observar que eles somente foram abordados, porque estavam em um ponto conhecido de venda de drogas, sendo que Eduardo estava na posse de anotações relativas à contabilidade da venda.

Vale ressaltar que havia outras duas pessoas no local, que foram liberadas, após a polícia constatar que eram moradores, sendo certo que Jean e Eduardo somente foram presos, porque em relação a eles, havia prova de que estavam praticando o comércio ilícito de entorpecentes.

Dessa forma, claro está que os réus estavam no local para vender entorpecente.

A materialidade delitiva também restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (págs. 21/22), laudo de constatação provisório (págs. 40/42) e exame químico toxicológico (págs. 459/461), os quais comprovaram a apreensão e a natureza de entorpecente das substâncias encontradas com os acusados.

Por fim, importante ressaltar que a polícia também apreendeu certa quantia em dinheiro, fruto, provavelmente, do comércio ilícito de entorpecente.

De outra feita, não é caso de desclassificar o crime para aquele previsto no art. 28 da Lei de Entorpecentes, conforme requerido pela defesa do réu Jean Pierry, ainda que o réu tenha afirmado ser usuário de drogas.

Isso porque, os policiais foram claros quando afirmaram que ele estava junto com Eduardo, quando da abordagem, tendo instantes antes, Jean filmado Eduardo na prática delitiva, sendo que os policiais também disseram que eles confessaram informalmente que estavam vendendo drogas, indicando ainda uma divisão de tarefas. Outrossim, as drogas foram localizadas próximas ao barraco onde eles foram abordados.

Ressalto que o fato dele ser, de fato, usuário de entorpecente e estar usando

drogas naquele local, não exclui, por si só, a possibilidade de ele também estar na posse das drogas para comercializá-las.

Portanto, havendo prova de que as substâncias eram entorpecentes (maconha, cocaína e 'crack'), em condições de tráfico (embaladas individualmente) e que os réus eram quem estavam com elas, em local conhecido como ponto de venda de drogas, não há outra solução, senão a condenação.

Com relação ao réu Lucas, todavia, a sua participação no crime não restou suficientemente demonstrada.

Com efeito, os policiais ouvidos afirmaram que nada de ilícito foi localizado com ele.

Outrossim, o réu quando interrogado em juízo negou a acusação, afirmando que estava no local apenas para usar droga.

Cumprir observar que sua versão não se mostrou inverossímil, não tendo sido afastada pelo conjunto probatório.

Assim, não há como negar a existência de indícios do crime. Todavia, estes indícios, produzidos na fase investigativa, não foram confortados nem mesmo repetidos na instrução contraditória, de modo que a incerteza acerca dos fatos conduz à absolvição do agente.

Diante das incertezas demonstradas na prova colhida, não se pode concluir com segurança pela autoria/participação de Lucas na prática delituosa, devendo, então, prevalecer o princípio "in dubio pro reo".

Passo à fixação das penas.

Primeiro, fixo a pena de Jean Pierre dos Santos Gomes.

Tendo em vista as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, e considerando que o acusado não ostenta antecedentes criminais, além daquele que ensejará sua reincidência na segunda fase, conforme comprova a certidão juntada nas págs. 486/487, bem como, considerando, ainda, sua culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, tendo ele agido com dolo normal para o tipo penal, fixo a pena – base para no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Considerando que o acusado é reincidente específico, conforme atesta a certidão de págs. 486/487, reconheço a existência da agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal e aumento a pena em um quarto, uma vez que ao incidir na mesma prática criminosa, demonstrou nada ter aprendido com a punição anterior, o que enseja uma reprimenda mais severa como forma de desestimulá-lo na reiteração desse tipo de conduta, o que totaliza seis anos e três meses de reclusão e seiscentos e vinte e cinco dias-multa.

Ainda na segunda fase, observo que o réu era menor de vinte e um anos na data do fato e, em vista disso, reconheço estar presente a atenuante da menoridade relativa, daí porque diminuo a sua pena em um sexto, o que perfaz cinco anos, dois meses e quinze dias de reclusão e mais quinhentos e vinte dias multa.

Por fim, deixo de reconhecer a causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que não estão presentes os seus requisitos legais, pois o réu é reincidente específico.

Agora, fixo a pena de Eduardo Alves Silva

Tendo em vista as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da lei nº 11.343/06 e, considerando que o acusado não ostenta antecedentes criminais, conforme comprova sua folha de antecedentes juntada às págs. 484, bem como, considerando, ainda, sua culpabilidade, motivo e circunstâncias dos crimes, tendo ele agido com dolo normal para o tipo penal, fixo a pena – base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes para serem consideradas.

Por fim, entendo que é caso de reconhecer a causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei, uma vez que presentes os seus requisitos, pois o réu é primário, não possui antecedentes criminais, não havendo qualquer prova no processo de que estivesse se dedicando à atividade criminosa ou de que integrasse organização criminosa. Por conta disso, diminuo a pena deste crime em dois terços, já que, dada as circunstâncias do caso concreto, verifica-se que ele estava se iniciando na vida criminosa, o que perfaz um 01 (um) ano e 08 (oito) meses de

reclusão e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, pena essa que torno definitiva.

O valor unitário do dia multa é fixado no mínimo legal, em virtude da situação econômica dos réus, retratada nos autos.

Com relação ao réu Jean Pierry, considerando que ele já foi processado e condenado por outro crime, impossível aplicar no caso destes autos o quanto disposto no art. 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei nº 12.736/12.

Isso porque, nesse contexto, não há como afirmar, com a necessária segurança, o efetivo tempo de sua prisão por estes autos, remanescendo, assim, a possibilidade desta consideração dar-se em momento posterior, na Vara de Execuções Criminais. Nos termos do que dispõe o art. 20, § 1º da Lei nº 8072/90, com a nova redação dada pela Lei nº 11.464/07, o regime para o cumprimento da pena de Jean Pierry será o inicialmente fechado. Com efeito, verifico que ele é reincidente, a evidenciar que possui uma personalidade desvirtuada, uma vez que a prática criminosa está presente em sua vida, de modo que a fixação de regime inicial mais brando, no caso em tela, não será suficiente para a reprovação de sua conduta, pois tal regime pressupõe a existência de senso de responsabilidade, qualidade essa que ele já demonstrou não possuir, pois voltou a delinquir, pouco tempo depois de ter cumprido sua pena anterior, não merecendo, assim, a confiança desse juízo.

Quanto ao réu Eduardo, nos termos do artigo 33, § 3º, letra 'c', do Código Penal, o regime para o cumprimento de sua pena será o inicialmente aberto, uma vez que as circunstâncias do caso concreto não denotam maior gravidade ou periculosidade em sua conduta.

Ainda, com a fixação de regime inicial menos gravoso no caso em tela, atende-se o quanto disposto em recente decisão emanada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de 'habeas corpus' coletivo nº 596.603/SP.

POSTO ISSO, e por tudo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE EM PARTE A DENÚNCIA, para condenar:

1- JEAN PIERRY DOS SANTOS GOMES, RG nº 52.905.65, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, esses fixados em seu valor unitário mínimo legal.

2- EDUARDO ALVES SILVA, RG nº 38.759.608, como incurso no artigo 33, "caput", c.c. §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, esses fixados em seu valor unitário mínimo legal.

E para ABSOLVER LUCAS OLIVEIRA AZEVEDO, da acusação do crime tipificado no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei nº 11.719/08.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo que a substituição da pena se mostra socialmente recomendável para o réu Eduardo, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a saber, prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, ambas pelo prazo da pena aplicada e que serão especificadas em sede de execução criminal.

Eduardo e Lucas poderão recorrer desta decisão em liberdade, diante do regime inicial fixado e da substituição ora feita, em relação a Eduardo e diante da absolvição de Lucas.

Jean Pierry não poderá recorrer desta decisão em liberdade, pois permaneceu preso durante toda a instrução.

Assim, se esteve cautelarmente preso durante a tramitação do feito, com maior razão a manutenção do cárcere após a prolação da presente sentença, até porque se trata de efeito da condenação (art. 393, inciso I, do Código de Processo Penal).

Indefiro, portanto, o recurso em liberdade.

Recomende-o preso ao estabelecimento prisional em que se encontra.

Com o trânsito em julgado e caso seja esta decisão mantida, tenham seus nomes lançados no rol dos culpados, providenciando a serventia, expedindo-se, também, ofício à autoridade policial para a incineração da droga apreendida, guardando, se o caso, eventual quantidade para contra-prova. (art. 32, § 1º da lei nº 11.343/06).

Nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06, declaro perdido em favor da União, a quantia apreendida (pág.21), providenciando-se o necessário Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Bernardo do Campo, 29 de julho de 2022.

LIZANDRA MARIA LAPENNA PEÇANHA

Juiza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA